

1502737-40.2019.8.26.0161

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... visando apurar denúncia anônima de tráfico droga, quando localizaram duas máquinas caça-níqueis.

A denúncia foi recebida em audiência, sem proposta de acordo de não persecução penal e ausentes os requisitos legais para os benefícios da transação penal, ante a reincidência do acusado conforme apontamentos de fls. 56/57.

O réu foi citado e nomeado Defensor Público que ofertou sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502737-40.2019.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502737-40.2019.8.26.0161

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3113235/2019 - 03º D.P. DIADEMA, 8120213 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Anderson de Souza Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

ANDERSON DE SOUZA FERREIRA, qualificado às fls. 06/07, está sendo processado como incurso no artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, porque no dia 21 de outubro de 2019, por volta das 13h00, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Terraço Lounge, situado na Avenida Prestes Maia, nº 1.126, nesta Comarca, estabeleceu e explorou jogo de azar em lugar acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele, pois segundo o apurado, policiais civis compareceram ao local visando apurar denúncia anônima de tráfico droga, quando localizaram duas máquinas caça-níqueis.

A denúncia foi recebida em audiência, sem proposta de acordo de não persecução penal e ausentes os requisitos legais para os benefícios da transação penal, ante a reincidência do acusado conforme apontamentos de fls. 56/57.

O réu foi citado e nomeado Defensor Público que ofertou sua defesa nesta audiência, na qual foi recebida a denuncia e também ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se o réu ao final.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada

autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, sem possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, entendendo possa ser fixado regime aberto.

Já o d. Defensor Público entendeu que o art. 50 da LCP não foi recepcionado pela CF/88. No mérito pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, reduzida pela confissão, com sua substituição por pena restritiva de direitos e possibilidade de apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Afasto preliminar da Defesa. Ora, o Decreto-Lei nº 3.688/41 é norma penal vigente, recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual deve ser aplicado àqueles que exploram jogo de azar. Neste sentido, já se pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal: "Com efeito, dos elementos constantes nos autos, observa-se que a máquina de caça níqueis de propriedade de José Guimarães dos Santos explorava jogos de azar que dependiam da sorte do apostador, em lugar acessível ao público. Ou seja, em princípio, é possível reconhecer a configuração dos elementos básicos da contravenção penal. Em decisão monocrática no AI no 201.483- MG, o Min. Relator Sydney Sanches afirma que a Lei das Contravenções Penais foi recepcionada pela atual Constituição Federal, in verbis: "(...)Como é de conhecimento de todos, a Lei das Contravenções Penais encontra-se em plena vigência, não tendo sido revogada pelo princípio constitucional da reserva legal. Embora tendo sido editada sob forma de decreto-lei, sua elaboração se deu em momento histórico e político em que era permitida a criação de tipos penais por aquela via. Também assim se deu com a parte especial do atual Código Penal que nasceu por meio de decreto. Era o que previa o processo legislativo na época". (AI no 201.483-MG, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 09/12/1999)" (STF, AI459909/SP; Rel Gilmar Mendes, DJe 17/8/2006). Grifei.

No mérito, a ação procede, anotando apenas que uma das máquinas estava sem numerário em seu interior que indicasse a exploração de jogo de azar, de modo que a denúncia procede com relação à máquina caça níquel operante e com valores em seu noteio, como veremos.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, auto de exibição e apreensão de objeto de fls. 10/11, e laudo pericial aferindo que a máquina apreendida se referia a jogo cujo ganho e perda dependia exclusivamente da sorte (fls. 28/31), contando com numerários em seu interior a indicar que foi efetivamente usada e que jogos foram feitos. Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato. Anoto, ianda, que

A autoria é inconteste.

O policial civil Genival Nascimento de Assis, ouvido em solo policial (fl. 06), declarou que realizou diligências com seu companheiro policial em um bar, com o intuito de averiguar denúncia anônima sobre a prática de traficância de drogas em tal local, conforme denúncia W190907741/19. Ao chegarem no estabelecimento comercial, conversaram com o proprietário, Anderson de Sousa Ferreira, indagando-o sobre a movimentação no local e sobre a denúncia de tráfico, fato negado pelo autor, e corroborado após breve vistoria. Durante a averiguação, observaram que haviam duas máquinas caça-níqueis no interior do bar, ambas desligadas, e que Anderson ao ser questionado sobre as duas máquinas, relatou que um indivíduo desconhecido, cuja qualificação, endereço ou telefone não soube informar, apresentou-se em seu estabelecimento e propôs deixar ali as duas máquinas, e que voltaria depois, nada negociando sobre a divisão de lucros provenientes da utilização das máquinas. Diante da falta de informações para a localização do dono das máquinas, o depoente e seu parceiro entraram em contato com autoridade policial, e solicitaram perícia para o local dos fatos, e após a realização da perícia, realizada pelo perito Dr. João, conduzindo Anderson, bem como dois noteiros e duas placas já periciadas no local dos fatos, e a quantia em dinheiro de R\$ 114,00 localizada no interior de uma das máquinas.

Em juízo essa testemunha asseverou que foram atender denuncia anônima cujo teor era

tráfico de entorpecentes no local. Não identificaram nada nesse sentido, mas havia duas máquinas no estabelecimento e questionado, ele informou que um desconhecido as teria deixado lá e que dividiriam os lucros do equipamento, mas ninguém tinha aparecido até então. Dentro das máquinas havia dinheiro embora não estivessem em funcionamento no momento. O réu confirmou que explorava o jogo, e que ele sabia para que fim que era, e se disse ser o responsável pelo estabelecimento alugado de outra pessoa o prédio, mas o comércio era dele, réu.

No mesmo sentido, em depoimento extrajudicial, o policial civil Daniel Candido Lopes, ouvido à fl. 07, informou que realizou uma diligência em um bar, acompanhado do policial Genival, com o intuito de averiguar denúncia anônima sobre a prática de traficância de drogas em tal local, denúncia W190907741/19. Ao chegarem no estabelecimento comercial, conversaram com o proprietário Anderson, indagando-o sobre a movimentação e sobre a denúncia de tráfico, fato negado pelo autor, e corroborado pelo depoente e seu parceiro após breve vistoria pelo local. Durante a averiguação, observaram que haviam duas máquinas caça-níqueis, ambas desligadas, e que Anderson ao ser questionado sobre as duas máquinas, relatou que um indivíduo desconhecido, cuja qualificação, endereço ou telefone não soube informar, apresentou-se em seu estabelecimento e propôs deixar ali as duas máquinas, e que voltaria depois, nada negociando sobre a divisão de lucros provenientes da utilização das máquinas. Diante da falta de informações para a localização do dono das máquinas, o depoente e seu parceiro entraram em contato com a Autoridade Policial solicitando perícia para o local dos fatos, e após a realização da perícia, conduziram Anderson, bem como dois noteiros e duas placas já periciadas no local dos fatos, e a quantia em dinheiro de R\$ 114,00 localizada no interior de uma das máquinas.

Em juízo esse policial alegou que o réu se disse o responsável pelo comércio e no local havia duas máquinas de caça niqueis que um desconhecido tinha deixado lá, e numa delas tinha dinheiro. Reconhece o réu.

O indiciado, em solo policial, ouvido às fls. 06/07, informou que é proprietário de um bar situado à Av. Prestes Maia, 1.126, Nações, nesta urbe, e que o nome do bar é Terraço Lounge. Declarou que na data dos fatos, exercia as suas atividades laborativas em seu estabelecimento, quando chegaram ao local dois policiais civis desta Unidade Policial. Os policiais indagaram o depoente sobre o horário de funcionamento do bar, sobre os funcionários, e em seguida passaram a olhar em seu interior, avistando duas máquinas caça-níqueis ali existentes, ambas desligadas. Indagado sobre o tempo que mantém tais máquinas no local, informou que há quatro meses, e que um conhecido cujo nome não sabe identificar indicou um outro indivíduo, cuja nome ou telefone também não sabe indicar, o qual apareceu na estabelecimento do depoente e deixou as duas máquinas. Informou que neste período, até a data da diligência dos policiais, tirava o lucro das máquinas para seu próprio benefício, uma vez que o indivíduo que deixou as máquinas em seu bar, cuja qualificação, endereço ou telefone não sabe informar, tampouco como possa ser localizado, nunca mais apareceu, nem para pegar o dinheiro do lucro das máquinas. Sob o crivo do contraditório o réu alegou que as máquinas caça niqueis estavam em seu comércio, um desconhecido ofereceu meio a meio do lucro, e se precisasse, ligasse para ele. Como estava precisando, aceitou porque o dinheiro ajudava a pagar umas contas. Sabia que o jogo não era lícito, mas como o aluguel estava atrasado, aceitou que as máquinas ficassem lá, e pegava uns trocos com elas.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, até porque corroborada pelas confissões policial e judicial do acusado, que não se tratam de prova única e veem corroboradas pelos relatos dos dois policiais, pela apreensão do maquinário, e pela prova pericial, como já visto.

Ora, como visto, foram apreendidas no estabelecimento comercial do acusado duas máquinas caça niqueis, havendo de se salientar que nos termos dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis, em diligência acerca de denúncia referente

a possível tráfico de drogas no local, encontraram as máquinas, e embora estivessem desligadas no momento, funcionavam consoante laudo pericial (fls. 28/31), restando indubitável a procedência de que os equipamentos se referiam a jogos cujo ganho e perda dependiam exclusivamente da sorte, tanto que em uma delas foi localizada uma quantia em dinheiro. Assim, o réu auferiu lucro com o maquinário, como ele próprio confessou.

Do laudo pericial (fls. 28/31), friso o seguinte excerto: "De acordo com as características externas das máquinas, dadas semelhanças com equipamentos utilizados para tal finalidade, cabe inferir que estas poderiam ser utilizadas para a prática de jogos de azar, ou seja, como sorteadoras de resultados, nos quais o ganho ou a perda independem de habilidade física ou mental do agente, isto é, dependem exclusivamente da sorte."

Portanto, o ganho ou perda independe da sorte do apostador, podendo, assim, ser utilizada para "jogo de azar", o que basta para a comprovação da materialidade delitiva. Não há como afastar a ilicitude da conduta, pois claramente o réu explorava jogo de azar, ainda que em serviço de terceiro, ou em sociedade com outro agente designado como proprietário da máquina, havendo em deixar os equipamentos em seu estabelecimento, em razão de informar que auferia das vantagens econômicas das máquinas caça niqueis. Sua conduta praticada contribuía para a exploração do jogo de azar praticado no estabelecimento.

Nesse passo, ante todo o conjunto probatório amealhado aos autos, a condenação é mesmo de rigor.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, os motivos, circunstâncias, consequências do delito, tratando-se de uma máquina apreendida, operante e utilizada para o jogo, a não demandar aumento inicial na pena, mas sim os maus antecedentes consoante condenação comprovada a fl. 66, a indicar que o crime desses autos não se tratou de um fato isolado na vida do agente, e para uma mais justa individualização, deve ser considerada a aumentar a pena base, donde a fixo, em primeira fase, em 04 meses de prisão simples e 13 dias-multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea a reduzir a pena a 03 meses de prisão simples e 10 dias-multa. Ausente agravantes a se considerar, conforme anotado pelo d. Defensor Público em debates orais.

Não concorrem causas de aumento nem de diminuição de pena na terceira etapa.

Cabível a benesse do art. 44 do CP, pois embora tenha má personalidade, tem-se que se trata de crime anão, mera contravenção, que não foi praticada com violência nem grave ameaça à pessoa, entendendo ser suficiente e eficaz à reprovação da conduta e ressocialização do agente, confesso inclusive, a pena restritiva de direitos, donde fixo a limitação de fim de semana pelo mesmo prazo da pena corporal.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, primariedade, pouca quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o aberto com o que inclusive está de acordo o Parquet.

Permito o recurso em liberdade, estando o réu solto, tendo comparecido a todos os atos processuais, valendo-me do princípio da presunção de inocência.

Sem valor mínimo de reparação de dano a ser fixado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra ANDERSON DE SOUZA FERREIRA, qualificado às fls. 06/07, como incurso no artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e o faço para condená-lo à pena de 03 meses de prisão simples, em regime aberto, substituído nos termos do art. 44 do CP por 03 meses de limitação de fim de semana, mais ao pagamento de 10 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do valor do salário mínimo à data dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O réu poderá apelar em liberdade.

Sem condenação nas custas processuais ante a assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente.

Determino a perda dos maquinários e do dinheiro apreendido, em favor da União.

Oficie-se TRE e IIRGD.

Fixo as condições do regime aberto: permanecer na residência durante o repouso e nos dias de folga, podendo sair apenas para tratamento médico, estudo ou trabalho, retornando ao término do expediente, e não frequentar pontos de venda de drogas, bares, bailes, festas, "baladas" e congêneres onde haja consumo de bebida alcoólica (art. 115, da Lei n.º 7.210/84).

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se

Diadema, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA